

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 92/2553

พนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง

โจทก์

นายศักดิ์ชัย เพชรกระจาย กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 90, มาตรา 289 (2)

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 78 วรรคสาม

การที่จำเลยทั้งสองขับรถจักรยานยนต์หนีโดยมีรถยนต์ของผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจไล่ตามมาติด ๆ เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร และจำเลยที่ 2 ขว้างลูกระเบิดไปข้างหลังโดยเล็งเห็นว่าลูกระเบิดที่ขว้างไปดังกล่าวสามารถทำให้ผู้เสียหายและพวกซึ่งอยู่ในรถยนต์ที่ไล่ตามมาอาจถึงแก่ความตายได้หากลูกระเบิดเกิดระเบิดขึ้น จึงเป็นการขว้างโดยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายกับพวก แต่การกระทำของจำเลยทั้งสองไม่บรรลุผล เพราะลูกระเบิดที่ขว้างไม่เกิดระเบิดเนื่องจากยังไม่ได้ถอดสลักนิรภัยซึ่งอาจเป็นเพราะจำเลยที่ 2 รีบร้อนเกินไป เมื่อปรากฏผลการตรวจพิสูจน์ลูกระเบิดว่าอยู่ในสภาพใช้การได้ หากเกิดระเบิดขึ้นมีอำนาจทำลายสังหารชีวิตมนุษย์ สัตว์ และทรัพย์สินให้เสียหายได้ในรัศมีจกบรรจุ 10 เมตร จากจุดระเบิดการกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายตาม ป.อ. มาตรา 289 (2) ประกอบด้วยมาตรา 80

การที่จำเลยทั้งสองร่วมกันมีลูกกระเบิดสังหารไว้ในครอบครองแล้วใช้ลูกกระเบิดสังหารดังกล่าวไปขว้างพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 289 (2), 80 และ พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด

ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ฯ มาตรา 78 วรรคสาม เป็นการกระทำความผิด
กรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 4, 7,
8 ทวิ, 55, 72, 72 ทวิ, 78 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 80, 83, 91, 289
(2), 371 ธิบฏกระเบิดของกลาง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่ก่อนสืบพยานจำเลยทั้งสองขอถอนคำให้การ
เดิมและให้การใหม่เป็นรับสารภาพตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7,
72 วรรคหนึ่ง, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง, 55, 78 วรรคหนึ่ง ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 371 ประกอบมาตรา 83 เป็นการกระทำความผิดหลายกรรม
ต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกคนละ
1 ปี ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบ
อนุญาต เป็นการกระทำความผิดเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 1 ปี ฐานมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้
ไม่ได้จำคุกคนละ 10 ปี รวมจำคุกคนละ 12 ปี จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 6 ปี ส่วนความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานให้ยก ธิบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (2) ประกอบมาตรา 80 และฐานใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิด นอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 55 ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ๔ ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 55, 78 วรรคสาม เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ๔ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกตลอดชีวิต ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 25 ปี รวมกับโทษจำคุกฐานร่วมกันมีและพาอาวุธปืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้ว เป็นจำคุกคนละ 25 ปี 12 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังยุติในชั้นนี้โดยคู่ความไม่ได้เถียงว่าในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยทั้งสองกับพวกขับรถจักรยานยนต์มุ่งหน้ามาถึงด่านซึ่งร้อยตำรวจตรีอนุกร ผู้เสียหายกับพวกตั้งจุดสกัด แต่ไม่ยอมหยุดให้ตรวจโดยขับรถจักรยานยนต์หลบหนี ผู้เสียหายกับพวกขับรถยนต์สายตรวจติดตามเมื่อตามไปถึงที่เกิดเหตุจำเลยที่ 2 ขว้างลูกระเบิดสังหารออกมา 1 ลูก ส่วนจำเลยที่

1 ใช้อาวุธปืนพกยิง 1 นัด ลูกกระเบิดไม่ระเบิดและกระสุนปืนไม่ถูกผู้ใด จำเลยทั้งสอง กับพวกหลบหนีไปได้ หลังเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจตรวจกู้ลูกกระเบิดซึ่งยังไม่ถอด สลักนิรภัยเป็นของกลางแล้วนำของกลางไปตรวจพิสูจน์ที่กองสรรพาวุธ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ผลการตรวจเป็นลูกกระเบิดขว้างสังหาร แบบเอ็มเค 2 ซึ่งทางราชการ ทหารและตำรวจเรียกว่าลูกกระเบิดขว้างสังหาร แบบ 88 บ.2 ของกลางอยู่ในสภาพใช้ การได้ เมื่อเกิดระเบิดขึ้นมีอำนาจทำลายสังหารชีวิตมนุษย์ สัตว์ และทรัพย์สินให้เสีย หายได้ในรัศมีณกรรจ์ 10 เมตร จากจุดระเบิด อันเป็นเครื่องกระสุนปืนที่นาย ทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตได้ สำหรับความผิดฐานร่วมกันมีลูกกระเบิดอันเป็น เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดย ผ่าฝืนต่อกฎหมาย ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดย ไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนและฐานร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ดังกล่าวติดตัวไปในหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว นั้นยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดดังกล่าว คง มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองก่อนว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันพยายาม ฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือไม่โดยจำเลยที่ 1 ฎีกาอ้างว่า กระสุนปืน ลูกซองที่ยิงออกไปในรัศมี 4 เมตร เป็นไปไม่ได้ที่ลูกกระสุนปืนเบอร์ 12 จะไม่ กระจายไปถูกรถยนต์ของผู้เสียหายกับพวกที่ขับตามหลังมาในระยะห่างประมาณ 40 ถึง 50 เมตร หากจำเลยที่ 1 เจตนาฆ่าผู้เสียหายจริงย่อมทำได้ตั้งแต่ขณะขับรถติดคู่ กันแล้ว ส่วนจำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 เพียงขว้างลูกกระเบิดของกลางทิ้งลงข้าง ทาง มิใช่ขว้างไปด้านหลังตามที่ผู้เสียหายให้การ หากเจตนาฆ่าผู้เสียหายจริงจำเลยที่ 2 ต้องถอดสลักนิรภัยออก เป็นไปไม่ได้ที่จะหลงลืมนั้น เห็นว่า เจ้าพนักงานตำรวจไม่ สามารถยึดอาวุธปืนจากจำเลยที่ 1 เป็นของกลาง จึงไม่แน่ชัดว่ากระสุนปืนดังกล่าว เป็นประเภทใด ซึ่งคงไม่ใช่กระสุนปืนลูกซองดังจำเลยที่ 1 อ้างเพราะมิเช่นนั้นเจ้า พนักงานตำรวจจะต้องตรวจพบชิ้นส่วนของปลอกกระสุนปืนที่จำเลยที่ 1 ยิงและการ

ที่จำเลยที่ 1 ไม่ยินยอมรถยนต์ที่ผู้เสียหายนั่งขณะขับรถติดคู่กันมาก็หาเป็นพิรุณไม่ เพราะต้องขึ้นอยู่กับโอกาสและจังหวะด้วย โดยโจทก์มีผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเบิกความยืนยันว่าจำเลยที่ 1 เอี้ยวตัววิ่งมาทางรถยนต์ที่ผู้เสียหายกับพวกไล่ตามหลังมาในระยะห่างเกิน 15 เมตร ซึ่งจำเลยที่ 1 น่าจะเล็งเห็นผลได้ว่าหากกระสุนปืนเข้าไปในรถยนต์ที่ผู้เสียหายกับพวกนั่งอยู่ อาจทำให้ผู้เสียหายกับพวกเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี้ผู้เสียหายยังเบิกความเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 ขว้างลูกระเบิดของกลางไปทางด้านหลังของจำเลยที่ 2 ซึ่งมีรถยนต์ของผู้เสียหายกับพวกติดตามมาด้านหลังครั้งแรกเข้าใจว่าเป็นยาเสพติด เห็นลูกระเบิดตกที่ถนนแล้วกลิ้งลงข้างทางห่างล้อหน้าซ้ายของรถยนต์ประมาณ 2 เมตร ศาลฎีกาเห็นว่าพฤติการณ์ที่จำเลยทั้งสองขับรถจี้รถยานยนต์หนีโดยมีรถยนต์ของเจ้าพนักงานตำรวจไล่ตามมาติด ๆ เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร การที่จำเลยที่ 2 ขว้างระเบิดออกไปน่าจะเพราะจำเลยทั้งสองกับพวกต้องการหลบหนีให้พ้นจากการติดตามของเจ้าพนักงานตำรวจมิใช่เพียงต้องการขว้างลูกระเบิดทิ้งเพื่อพ่นผิด ทั้งคดีนี้จำเลยทั้งสองมีทนายความซักค้านพยานปากผู้เสียหายแต่ไม่สามารถซักค้านทำลายน้ำหนักคำเบิกความของผู้เสียหายได้ และผู้เสียหายคงเบิกความตอบทนายจำเลยทั้งสองถามค้านยืนยันเช่นเดิมว่าจำเลยที่ 2 ขว้างลูกระเบิดออกไปทางด้านหลังซึ่งผู้เสียหายกับพวกนั่งรถยนต์ไล่ตามมา เมื่อจำเลยทั้งสองไม่นำพยานเข้าสืบหักล้างและยังให้การรับสารภาพในชั้นศาลว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันพยายามฆ่าผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานกระทำการตามหน้าที่จริง ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยที่ 2 ขว้างลูกระเบิดของกลางไปข้างหลังโดยเล็งเห็นว่าลูกระเบิดที่ขว้างไปดังกล่าวสามารถทำให้ผู้เสียหายและพวกซึ่งอยู่ในรถยนต์ที่ไล่ตามมาอาจถึงแก่ความตายได้หากลูกระเบิดเกิดระเบิดขึ้น จึงเป็นการขว้างโดยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายกับพวก แต่การกระทำของจำเลยทั้งสองไม่บรรลุผล เพราะลูกระเบิดที่ขว้างไม่เกิดระเบิดเนื่องจากยังไม่ได้ถอดสลักนิรภัยซึ่งอาจเป็นเพราะจำเลยที่ 2 รีบร้อนเกินไป เมื่อปรากฏจากผลการตรวจ

พิสูจน์ลูกระเบิดของกลางว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้ หากเกิดระเบิดขึ้นมีอำนาจทำลายสังหารชีวิตมนุษย์ สัตว์ และทรัพย์สินให้เสียหายได้ในรัศมีจกัรรัจ 10 เมตร จักจุดระเบิด การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (2) ประกอบด้วยมาตรา 80 ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

ปัญหาสุดท้ายที่โจทก์ฎีกาว่า ความผิดฐานร่วมกันมีลูกระเบิดสังหารอันเป็นเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตได้เป็นคนละกรรมกับความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนหรือวัตถุระเบิด นอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 55 ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ๗ นั้น เห็นว่า การที่จำเลยทั้งสองร่วมกันมีลูกระเบิดสังหารไว้ในครอบครองแล้วใช้ลูกระเบิดสังหารดังกล่าวไปในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (2) ประกอบด้วยมาตรา 80 ถือว่าเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท เทียบตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1350/2540 ซึ่งวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ หาใช่เป็นความผิดหลายกรรมไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ๗ มาตรา 55 และ 78 วรรคสาม ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 25 ปี เพียงกรรมเดียว โดยไม่นำโทษจำคุกฐานมีระเบิดสังหารอันเป็นเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตได้มารวมด้วยจึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อัปษร หิริญญบุรณะ-วิระวัฒน์ ปวรจารย์-เมทินี ชโลธร)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ บัญญัติไว้ว่า มาตรา 55 ประเภท ชนิด และขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตามมาตรา 7 มาตรา 24 หรือมาตรา 38 ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 78 ผู้ใดทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ ชื่อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้าซึ่งอาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 55 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงจำคุกตลอดชีวิต ผู้ใดค้า หรือจำหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 55 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ยี่สิบปีถึงจำคุกตลอดชีวิต ผู้ใดใช้อาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นอกจากที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 55 ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 มาตรา 313 มาตรา 339 หรือมาตรา 340 ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต การกระ ทำความผิดตามวรรคสองหรือวรรคสาม ถ้าอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ ระเบิดนั้น โดยสภาพมีอำนาจไม่ร้ายแรงต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงจำคุก ตลอดชีวิต การที่จำเลยมีระเบิดไว้ในครอบครอง แล้วใช้ระเบิดนั้นขว้างพยายามฆ่าผู้ อื่นจะเป็นความผิดก็กรรม และเป็นความผิดฐานใดบ้าง เคยมีการวินิจฉัยโดยที่ ประชุมใหญ่ของศาลฎีกามาแล้วซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วินิจฉัยเดินตาม คือคำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 1350/2540 การประชุมใหญ่อ้างว่ามีหัวข้อในการอภิปรายดังนี้

1. การมีระเบิดไว้ในครอบครองและใช้ระเบิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ มาตรา 78

วรรคหนึ่งกับวรรคสามเป็นกรรมเดียวหรือสองกรรม ความเห็นแรก เป็นความผิดสองกรรมเพราะเมื่อมีระเบิดไว้ในครอบครองก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว เมื่อนำไปใช้ก็เป็นความผิดอีกกรรมหนึ่ง ความเห็นที่สอง มาตรา 78 วรรคหนึ่ง บัญญัติความผิดไว้รวมกันว่าทั้งมีและใช้ ดังนั้น เมื่อมีระเบิดไว้ในครอบครองแล้วนำไปใช้จึงเป็นกรรมเดียว หากตีความว่าเป็นสองกรรม เป็นการตีความขยายผลให้เป็นผลร้ายแก่จำเลย เป็นการไม่ชอบ ที่ประชุมใหญ่โดยเสียงข้างมากเห็นว่าเป็นกรรมเดียว 2. การใช้ระเบิดขวางพยายามฆ่าที่เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 288, 80 จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ มาตรา 78 วรรคสาม หรือไม่ ที่ประชุมใหญ่โดยเสียงข้างมากเห็นว่าเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ ด้วย 3. เมื่อเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ มาตรา 78 วรรคสาม แล้วรับโทษเต็มหรือรับโทษ 2 ใน 3 (ตาม ป.อ. มาตรา 80) ความเห็นแรก รับโทษ 2 ใน 3 ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ มาตรา 78 วรรคสาม ประกอบ ป.อ. มาตรา 80 เพราะลงมือกระทำไปแล้ว แต่ไม่บรรลุผล หากลงโทษเต็มจะไม่ตรงตามตัวบทและเป็นผลร้ายแก่จำเลย ความเห็นที่สอง เป็นความผิดสำเร็จเมื่อมีการใช้ระเบิดโดยไม่ต้องพิจารณาว่า ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร เพราะกฎหมายใช้คำว่า ใช้ โดยไม่พิจารณาผลที่เกิด ดังจะเห็นได้ว่าความผิดตาม ป.อ. มาตรา 288, 80 มีโทษตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป แต่ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ มาตรา 78 วรรคสาม หากนำไปใช้ในการกระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 317 และ 339 ก็ต้องลงโทษตามมาตรา 78 วรรคสาม ซึ่งโทษตามมาตรา 337 จำคุก 6 เดือน ถึง 7 ปี ความผิดตามมาตรา 339 วรรคหนึ่งและวรรคสอง จำคุก 10 ปี ถึง 15 ปี เป็นโทษที่น้อยกว่าโทษตามมาตรา 288, 80 เสียอีก ที่ประชุมใหญ่โดยเสียงข้างมากเห็นว่รับโทษเต็ม เท่ากับว่าความผิดตามมาตรา 78 วรรคสาม เป็นความผิดสำเร็จเสมอ จะเป็นความผิดฐานพยายามไม่ได้ ผู้หมายเหตุเห็นด้วยกับที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดสำเร็จตามมาตรา 78 วรรคสาม ตามเหตุผลที่ยกขึ้นดังกล่าว แต่การที่วินิจฉัยว่าการกระทำฐานมีระเบิดและใช้เป็นกรรมเดียวนั้น

มีข้อสังเกตว่า การใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนสามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ไม่มี
บทบัญญัติว่าเป็นความผิด ต่างจากการใช้อาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบ
อนุญาตได้ที่บัญญัติเป็นความผิดไว้เฉพาะดังกล่าว จึงทำให้คิดไปได้ว่าการมีกับการ
ใช้เป็นกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตามผู้หมายเหตุเห็นว่าการที่จำเลยมีระเบิดไว้ใน
ครอบครองก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว เมื่อนำไปใช้อาจเป็นกรรมเดียวหรือสองกรรม
แล้วแต่นำไปใช้อะไร หากนำไปใช้กระทำอย่างอื่นที่มีใช้การกระทำความผิดฐาน
ใดฐานหนึ่งตาม ป.อ. มาตรา 288, 313, 337, 339 และ 340 ที่ระบุไว้ในมาตรา 78
วรรคสาม เช่น จำเลยใช้ระเบิดที่มีไว้ในครอบครองปาใส่สัตว์ป่า หรือจำเลยใช้ระเบิด
ที่มีไว้ในครอบครองขว้างใส่ผู้เสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจสลักออกเช่นนี้เป็นความผิดตาม
มาตรา 78 วรรคหนึ่ง กล่าวคือเป็นกรรมเดียวหากนำไปใช้กระทำความผิดฐานใดฐาน
หนึ่งที่กำหนดไว้ในมาตรา 78 วรรคสาม ก็เป็นความผิดอีกกรรมหนึ่งต่างหากจากการ
มีไว้ในครอบครอง ศิริชัย วัฒนโยธิน